

1500134-15.2022.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... drogas (ato infracional equiparado a tráfico - proc. 0000190-64.2018.8.26.0411, além de "denúncias" por envolvimento com o tráfico), afastando, desse modo, a figura do tráfico privilegiado (STJ - AgRg no HC 731065 / SP; AgRg no HC 674306 / MG; EREsp 1.916.596/SP).

Ressalte-se que, conforme entendimento doutrinário, a referida causa de diminuição apenas "deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

1500134-15.2022.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500134-15.2022.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉSSICA PIVETA DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

JÉSSICA PIVETA DE MORAES, qualificada nos autos, foi denunciada perante este Juízo como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de abril de 2022, por volta das 22h40min, na Avenida Euclides Cunha, 732, centro, no município de Irapuru, nesta Comarca, a ré trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 04 (quatro) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido total de 40,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da peça acusatória que, na data dos fatos, após denúncias de que a ré estaria praticando a venda de entorpecentes próxima à rodoviária, os policiais militares se dirigiram até o local e a encontraram conversando com cinco egressos do sistema prisional. Narra ainda que, passado algum tempo, diante de nova denúncia de comércio de drogas, os policiais retornaram ao local, onde, novamente, encontraram a ré, que, ao avistá-los, dispensou objeto ao solo e tentou ocultá-lo com os pés. Por fim, a denúncia informa que, durante a abordagem da ré, os policiais encontraram quatro porções de maconha e a quantia de R\$ 45,00, envoltos em uma máscara facial (fls. 72/73).

Defesa prévia da ré às fls. 89/91.

A denúncia foi recebida às fls. 110/112.

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do réu (fls. 133/135 – gravação audiovisual).

Em alegações finais, apresentadas sob a forma de memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré. No tocante à dosimetria, indicou a possibilidade de fixação da pena no patamar mínimo legal. Postulou ainda, o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial fechado, sem substituição por pena restritiva de direitos (fls. 156/162).

A defesa, por seu turno, alegou que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo da ré, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena em patamar mínimo, a concessão do direito de recorrer em liberdade e o estabelecimento do regime inicial semiaberto (fls. 168/177).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

De início, a materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo pericial de fls. 151/153, documentos de fls. 29/30, bem como pelos demais elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, corroborados com a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual modo, é indubitosa.

O policial militar RICARDO DELGADO DE OLIVEIRA, ouvido na condição de testemunha, disse que havia várias informações de que a ré comercializava entorpecentes e que, no dia dos fatos, ela foi avistada na rodoviária do município conversando com 05 detentos que estavam em liberdade. Afirmou que receberam ligação informando que a ré estava vendendo drogas àqueles indivíduos, razão pela qual retornaram ao local, onde não encontraram mais a ré, que havia se deslocado a uma barbearia da cidade, onde havia várias outras pessoas. Aduz que o policial Calegon solicitou apoio de policiais de outros municípios, que, ao chegarem ao local, procederam à revista dos presentes, sendo que a ré fora revista pela cabo Martinez. Disse que a ré, ao avistar a viatura policial, lançou um objeto ao chão e pisou sobre ele, sendo, posteriormente constatado, durante procedimento de revista, que se tratava de uma máscara facial contendo quatro invólucros e R\$ 45,00 em dinheiro.

No mesmo sentido depôs o policial militar PAULO SÉRGIO CALEGON, também inquirido na condição de testemunha. Ratificou que havia várias “denúncias” contra a ré, tanto na polícia militar, quanto na polícia civil. Afirmou que a ré negou a posse dos entorpecentes, mas informou que ela possui histórico de envolvimento com drogas, sendo, inclusive, presa duas vezes quando menor de idade.

Em seu interrogatório, a ré negou a prática de tráfico de drogas. Afirmou que estava sentada à frente da barbearia, onde havia egressos do sistema prisional, com os quais nega ter mantido contato, momento em que foi abordada pelos policiais. Disse que havia mais de 25 pessoas no local, que as drogas estavam ao lado de seu pé, mas não lhe pertenciam, e que em nenhum momento tentou esconder os entorpecentes. Admitiu ser usuária de entorpecentes desde os 14 anos de idade, mas

negou a propriedade das drogas apreendidas

Pois bem.

A princípio, necessário ressaltar que, conforme jurisprudência sedimentada no STJ (HC 395.325, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/05/2017), os depoimentos de servidores públicos, como é o caso dos policiais militares, são plenamente válidos, merecendo credibilidade. No mesmo sentido, o E. TJSP já decidiu nos seguintes termos:

"Como é cediço, nada impede que policiais e guardas municipais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.

Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito."

(TJSP - Apelação criminal nº 1527289-91.2021.8.6.0228. Rel. Des. Hermann Herschander. Dje.: 06/05/2022).

Deste modo, diante da prova oral produzida em Juízo, restou evidenciada a responsabilidade penal da ré, havendo adequação típica entre a conduta por ele perpetrada e o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja conduta típica consiste em "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Com efeito, a instrução evidenciou que a réu trazia consigo, aproximadamente, 40,9g de maconha (auto de exibição e apreensão de fls. 16), embora o tenha negado em seu interrogatório judicial. Além disso, a prova testemunhal indica que os entorpecentes eram destinados à venda, caracterizando, portanto, tráfico ilícito.

Ademais, não merece acolhimento a alegação de que os entorpecentes se destinavam a uso próprio, tendo em vista a considerável quantidade apreendida, a existência de registros e "denúncias" relacionados ao tráfico e o fato de ter sido encontrado dinheiro junto à substância entorpecente, tudo a afastar a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, indicando a prática da traficância.

Vale mencionar que a quantidade de droga apreendida constitui um dos elementos legais de distinção entre o usuário e o traficante, conforme prevê o § 2º, do já mencionado artigo 28. Tal elemento, aliado ao relato dos policiais de que havia denúncias de traficância pela ré, impossibilita a caracterização do crime de porte de drogas para consumo pessoal, evidenciando a ocorrência de tráfico de drogas. Não é outro o entendimento da jurisprudência. Neste sentido:

"Deveras, a quantidade da droga, embora não seja exclusivo, constitui fator importante para a caracterização do tráfico (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção Repressão, Saraiva, 1992, pág. 182).

Consoante já se decidiu, "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág.

3190)."

(TJSP - Apelação Criminal. Rel. Des. Laerte Marrone. Dje. 31/05/2022).

Ressalte-se que a legislação brasileira segue o chamado "sistema de reconhecimento judicial ou policial", o qual "não estabelece uma quantidade de droga como parâmetro rígido e inquebrantável para diferenciar o usuário do traficante. Ao revés, a Lei traz alguns critérios que serão verificados à luz do caso concreto, inicialmente pela autoridade policial (por ocasião de uma eventual prisão em flagrante) e, posteriormente, pela autoridade judiciária" (ROQUE, F.; TÁVORA, N.; ALENCAR, R. R. 2020, p. 633).

Por fim, é irrelevante que a acusada seja também usuária de drogas, posto que tal fato, por si só, não descaracteriza a traficância, que, muitas vezes, é utilizada como recurso para sustentação do vício em entorpecentes.

Portanto, sendo necessária a condenação pelo cometimento de tráfico de drogas, passo à dosimetria da pena a ser imposta ao réu.

Na primeira fase de dosimetria, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (FA e certidão de fls. 129/131 e 32), fixo a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes que possam incidir sobre a pena-base.

Por fim, na terceira e derradeira fase de dosimetria, revela-se incabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.373/06. Embora seja tecnicamente primária, a prova testemunhal indica que a ré se dedica a atividades criminosas, possuindo histórico de envolvimento com drogas (ato infracional equiparado a tráfico - proc. 0000190-64.2018.8.26.0411, além de "denúncias" por envolvimento com o tráfico), afastando, desse modo, a figura do tráfico privilegiado (STJ - AgRg no HC 731065 / SP; AgRg no HC 674306 / MG; EREsp 1.916.596/SP).

Ressalte-se que, conforme entendimento doutrinário, a referida causa de diminuição apenas "deve beneficiar aquele que não faz do crime um meio de vida, não age com habitualidade. Se restar comprovado que o agente se dedicava a atividades criminosas, para além do tráfico a que responde, impossível a incidência da causa de diminuição. Importante destacar que não há necessidade de se comprovar que o agente foi condenado por outros crimes. Não. Pode ocorrer de, no curso da instrução, haver a comprovação do envolvimento do agente em outras atividades e aprova produzida nesse processo, ainda que em relação a outros crimes, já será o suficiente para afastar o benefício penal" (ROQUE, F.; TÁVORA, N.; ALENCAR, R. R. 2020, p. 633).

Sendo assim, evidenciada a ausência de causas de aumento e diminuição, torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a natureza equiparada a hedionda, a gravidade da infração penal e a conduta social reprovável da ré, caracterizada pela prática de delitos relacionados a entorpecentes (art. 33, § 3º e 59, inciso III, do Código Penal). Ressalte-se que, em caso semelhante, inclusive desta Comarca, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu nos seguintes termos:

"No tocante ao regime, é entendimento sedimentado nesta Câmara que o regime prisional fechado, imposto por texto expresso de lei, é o único compatível com a gravidade do delito praticado.

Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente concede a infratores de normas diversas."

(E. TJSP – Apelação criminal nº 1501332- 92.2019.8.26.0411. Rel. Des. Marcos Correa. Dje. 25/05/2022).

Ademais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada ultrapassa a 4 anos, impedindo a aplicação do art. 44, do Código Penal.

Considerando a condição econômica da ré, o valor diário da multa será correspondente ao mínimo legal, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR a ré JÉSSICA PIVETA DE MORAES como incurso no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Nego à ré o apelo em liberdade, eis que se encontra presa por este processo (fls. 34/38), estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, é necessária a custódia da ré, reiterando-se o ressaltado às fls. 34/38 e 97/100, eis que condenada a pena a ser cumprida em regime fechado, de modo, que, certamente, se libertada for, procurará se evadir, frustrando a aplicação da lei penal. Ademais, a acusada foi condenada por crime grave, que enseja grande parte da criminalidade havida na sociedade, sendo a sua custódia necessária à garantia da ordem pública.

Vale mencionar, por fim, que conforme entendimento do STJ, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), bem como que "a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede ao agravante que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 732146/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Dje. 20/05/2022).

Por tais razões, nego à ré o apelo em liberdade.

Recomende-se a ré na prisão em se encontre recolhida.

Transitada esta em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Caso necessário, expeça-se certidão de honorários no valor máximo fixado em tabela, em consonância com os atos praticados.

Custas nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade).

P.I.C.

Pacaembu, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA